

0017965-69.2022.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Magistrado: MARCIO LUCIO FALAVIGNA SAUANDAG

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 22ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/09/2022

... Tudo porque a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes independe da efetiva venda da droga, estando bem delineada nos autos a configuração do delito de tráfico na modalidade de "vender, oferecer e trazer consigo" o entorpecente.

Não reconheço a majorante encerrada na denúncia, dada a precariedade da prova, encimada, unicamente, na prova vocal, e, tão só, ainda ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

22ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0017965-69.2022.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0017965-69.2022.8.26.0050

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALECSO DA SILVA CRUZ

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCIO LUCIO FALAVIGNA SAUANDAG

Vistos.

ALECSO DA SILVA CRUZ foi denunciado e se vê processado pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, porque, em 01 de julho de 2022, por volta de 09h17, na Rua Capitão Pucci, altura do nº 82, Vila Minerva, nesta cidade e Comarca da Capital, nas imediações do estabelecimento de ensino EMEF Professor João De Lima Paiva, vendia, oferecia e trazia consigo drogas, para entrega de qualquer forma a consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistentes em 12 (doze) invólucros plásticos ("papelotes") contendo 11,2g (onze gramas e dois decigramas) de substância Tetrahydrocannabinol (THC), conhecida como maconha, e 144 (cento e quarenta e quatro) invólucros plásticos contendo 65,2g (sessenta e cinco gramas e dois decigramas) de cocaína, cf. boletim de ocorrência de fls. 02/05, laudo de constatação de fls. 16/18, auto de exibição e apreensão de fls. 19/21 e fotografia de fl. 26.

Recebida a Denúncia, o acusado foi citado, sendo apresentada Resposta à Acusação, seguindo-se a decisão saneadora.

Em audiência foi colhida a prova oral e interrogado o acionado.

Ponderações finais das partes em debates.

Auto de Exibição e Apreensão do Entorpecente, a fls. 19/20.

Laudo de Constatação a fls. 17/18.

Laudo de Exame Químico-Toxicológico, a fls. 83/85.

Comprovante de recolhimento judicial do valor apreendido com o acusado (R\$ 108,00), a fls. 86.

É o relato do quanto necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A condenação se mostra de rigor. Porém, com algum temperamento.

A materialidade do crime encontra esteio no Auto de Exibição e Apreensão de fls. 19/20, Laudo de Constatação de fls. 17/18 e Laudo Pericial de fls. 83/85, onde se infere que os materiais apreendidos com o acionado se tratavam, efetivamente, de substâncias entorpecentes, no caso, maconha e cocaína.

A autoria do crime de tráfico imputado ao acionado ecoa da prova produzida, evidenciada sua participação ativa na venda do entorpecente.

Interrogado na fase policial, o acionado optou por permanecer em silêncio, atitude que não se espera de quem se diz inocente (fls. 08).

Em Juízo, negou a acusação.

Contudo, apresentou enredo fantasioso e inventivo, de todo embusteiro e inverossímil, revelador, unicamente, do espírito aguerrido e aventureiro do criminoso, de simplesmente pretender negar o óbvio, com nítido desprezo ao bom senso, algo a que não me atrevo, tampouco posso admitir.

Triste investida!

Doutro lado, temos os relatos precisos e harmônicos dos guardas civis responsáveis pela prisão do acusado.

Ouvidos em Juízo, os guardas civis metropolitanos Antonio Roberto Pereira Cardoso e Jean Cavalcante Barbosa declararam que, que estavam em patrulhamento, quando, no local dos fatos, próximo a escola municipal quando avistaram um indivíduo entregando algo que suspeitaram ser drogas. Que, de imediato, abordaram o indivíduo, o qual estava com uma sacola em suas mãos, sendo encontrado dentro desta, várias porções de entorpecentes variados, no caso maconha e cocaína. Em suas vestes encontraram valores em dinheiro de contado, em notas trocadas. Indagado sobre os fatos, negou que estivesse traficando. Nesse cenário, foi dada voz de prisão em flagrante ao acionado.

Neste ponto, nem se argumente acerca da nulidade da prova, sob o prisma de que realizada a prisão por guarda civil metropolitano, na medida em que, no caso, não se desenvolveu, pelos referidos guardas, algum ato de investigação. Na verdade, exerciam sua atividade fim, patrulhando, ao que se parece, nas imediações de estabelecimento de ensino, e, como qualquer do povo, se depararam com a situação de fato criminoso, oportunidade em que agiram na prisão.

Portanto, não se pode alegar eiva alguma na prova, sempre respeitado entendimento contrário.

Sobre o tema: Esta Corte entende que inexiste óbice à realização de prisão, em situação de flagrância, por guardas municipais ou qualquer outra pessoa, não havendo falar, em tais casos, em ilicitude das provas daí decorrentes. A propósito: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO CONFIRMADA PELO TRIBUNAL A QUO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA. CONDUTA FLAGRADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Se o Tribunal de origem, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, concluiu, de forma fundamentada, não só pela materialidade do delito, mas também por ser o réu autor do crime descrito na exordial acusatória, não cabe a esta Corte a análise das afirmações relacionadas ao pleito de absolvição, na medida em que demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 3. O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art.

563 do CPP (pas de nullité sans grief). 4. Firme o entendimento jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: "Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode prender quem esteja em flagrante delito, razão pela qual não há qualquer óbice à sua realização por guardas municipais. Precedentes." (HC 357.725/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 12/5/2017). 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 332.635/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017.) (HABEAS CORPUS Nº 667.461 - SP (2021/0152341-3) RELATOR: MINISTRO OLINDO MENEZES, j. em 14 de setembro de 2021).

Neste quadro, dúvida não me paira de que o acionado vendia, oferecia e trazia consigo drogas, para entrega de qualquer forma a consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistentes em 12 (doze) invólucros plásticos ("papelotes") contendo 11,2g (onze gramas e dois decigramas) de substância Tetrahidrocannabinol (THC), conhecida como maconha, e 144 (cento e quarenta e quatro) invólucros plásticos contendo 65,2g (sessenta e cinco gramas e dois decigramas) de cocaína, marcadamente destinadas à entrega para o consumo de terceiros, mormente porque o acionado não demonstrou condições econômicas para ter as drogas unicamente para seu deleite pessoal, sequer comprovando possuir emprego lícito.

Consigno que nada há nos autos a indicar que os guardas civis, por motivo egoístico ou leviano, tivessem urdido macabra trama, como única pretensão na vida acusar o acionado, sabendo se tratar de pessoa inocente.

No caso em espécie, nenhuma razão séria foi levantada para que se colocasse em dúvida a idoneidade das testemunhas ou gerasse suspeita de especial motivo para prejudicar o acusado.

A quantidade de drogas apreendidas, num total de 156 (cento e cinquenta e seis) porções de entorpecentes variados e de alta lesividade, as circunstâncias do flagrante, a apreensão de dinheiro em espécie com o réu, num total de R\$ 108,00, os depoimentos firmes dos guardas civis que abordaram o acusado, enfim, todo o arcabouço probatório aponta para a conclusão inarredável de que o réu efetivamente praticou a conduta criminosa que lhe é imputada pelo Órgão Ministerial.

De tal forma, da prova se extrai que efetivamente o réu praticou a conduta descrita na Denúncia, sendo inviável a pretensão absolutória ou desclassificatória.

Com efeito, irrelevante se mostra a não identificação precisa do cliente. Tudo porque a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes independe da efetiva venda da droga, estando bem delineada nos autos a configuração do delito de tráfico na modalidade de "vender, oferecer e trazer consigo" o entorpecente.

Não reconheço a majorante encerrada na denúncia, dada a precariedade da prova, encimada, unicamente, na prova vocal, e, tão só, ainda mais, de forma tímida, máxime tendo em mira o conceito absolutamente subjetivo das testemunhas.

Com efeito, a acusação não se preocupou de acostar aos autos prova técnica a indicar que, realmente, os fatos tomaram forma em local próximo a estabelecimento de ensino, o que seria necessário, a vista do comando que emerge do disposto no art. 158, do CPP.

Pior, sequer se preocupou, a par da ausência de prova técnica, juntar aos autos um documento indicativo da distância entre o local dos fatos e a referida Escola Municipal de Ensino Fundamental, o que absolutamente fácil nos dias de hoje, a vista de inúmeras ferramentas tecnológicas dispostas na rede mundial de computadores, mesmas ferramentas que, diante da curiosidade, este Juízo consultou, verificando que o local dos fatos dista mais de trezentos metros da tal Escola, o que não se conforma com a ideia de proximidade que o legislador procurou dispor de forma a censurar com maior vigor a atividade ilícita em questão.

Ainda, a acusação também não procurou fazer prova firme que, na data dos fatos, a escola estava em funcionamento, e que o recesso escolar de meio de ano, dada a data do fato, ainda não tinha iniciado.

Por fim, forçoso identificar, ainda, que a prova não veio de molde a demonstrar, sem qualquer dúvida, de que aquela atividade criminosa realizada pelo acionado mirava os frequentadores do estabelecimento de ensino, consoante se dirige a jurisprudência paulista, o que não se pode simplesmente presumir.

Sobre o tema: Pese o pleito ministerial, deve ser afastada a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06. Apesar da existência de estabelecimentos de ensino nas proximidades, como se observa do laudo de fls. 99/105-A, não há prova nos autos de que os réus visavam os frequentadores dos referidos lugares. Veja-se que, embora os policiais tenham relatado haver indivíduos em volta do carro dos apelados, não se pode afirmar sejam eles frequentadores daqueles locais determinados. A simples proximidade física ou geográfica, sem relação com a prática do crime, não autoriza a aplicação da causa de aumento, até porque algumas vezes poderá ocorrer que o agente nem mesmo saiba estar nas imediações de um daqueles locais referidos no inciso III (Apelação nº 0073136-26.2013.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. em São Paulo, 2 de outubro de 2014, rel. Desembargador ALCIDES MALOSSI JUNIOR); Por outro lado, na terceira fase, o acréscimo pela qualificadora do art. 40, inciso III, da Lei de Drogas (cometimento da infração em local próximo a estabelecimento de ensino), deve mesmo ser afastado, uma vez que sua incidência não restou fundamentada na decisão. Na verdade, o que se vê nos autos, é que o laudo de fls. 75/97 se limita a informar que a prisão aconteceu há aproximadamente 45 metros de distância da "Unidade Municipal de Ensino do Estado do Maranhão", sem qualquer outra indicação ou prova de que a ação do apelante estava direcionada ao público que frequentava o local. Até porque, segundo o laudo, a escola destinava-se a atender alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental (fls. 76), ou seja, crianças com aproximadamente entre 6 a 10 anos de idade e que provavelmente não frequentavam a escola no horário em que o traficante exercia a atividade ilícita (22h40min fls. 08). Dessa forma, o que se tem é simples presunção, que, com a devida vênia, não pode justificar a qualificadora em questão se nada sugere a maior gravidade da ação e tampouco a sentença indicou os motivos que levaram ao reconhecimento da causa de aumento de pena (Apelação nº 0002863-60.2011.8.26.0157, 4ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. em 31 de julho de 2014, rel. Desembargador ALEXANDRE ALMEIDA). Bem firmadas as responsabilidades do réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, passo a mensurar a censura adequada. Em primeira fase, as circunstâncias judiciais não se mostram absolutamente desfavoráveis ao acusado.

Destarte, fixo suas penas iniciais no mínimo legal.

Em segunda fase, sendo ausentes atenuantes, se mostra presente a circunstância agravante da dupla reincidência, na medida em que o réu possui duas condenações anteriores pela prática dos crimes de receptação (proc. 0009901-71.2016-2ª Vara Criminal) e de roubo (proc. nº 1515.928-48.2019-31ª Vara Criminal).

Assim, frente a tais ponderações, majoro as reprimendas em 1/5, encerrando o cumprimento de pena privativa de liberdade de seis anos de reclusão, bem como o pagamento de pena pecuniária em valor equivalente a seiscentos dias multa.

Em terceira etapa da dosimetria, ausente a causa de aumento de penas, consoante acima fundamentado.

Outrossim, consigno ser inaplicável o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, dada a condição de reincidente que milita em desfavor do acusado.

Penas finais: O cumprimento de pena privativa de liberdade de seis anos de reclusão e pagamento de pena pecuniária em valor equivalente a seiscentos dias multa, fixados no valor unitário mínimo.

O sentenciado cumprirá a pena corporal aplicada pela prática do delito descrito no artigo 33, caput, da Lei Federal nº 11.343/06, em regime inicial fechado, em atenção ao comando que emerge do parágrafo 1º, artigo 2º da Lei 8.072/90, único suficiente e adequado a reprimir o desvio de conduta, mormente em se tratando de acionado reincidente.

No que tange a eventual substituição da pena corporal pela restritiva de direitos, observo que o quantum da pena aplicada impede a concessão da benesse disposta no art. 44, do CP, eis que fixada acima do limite legal de quatro anos, conforme prevê o inciso I do citado artigo. Além disso, a substituição da pena privativa de liberdade encontra óbice na condição de reincidente, que ostenta o réu, nos exatos termos do artigo 44, inciso II, do CP. Assim, inviável aplicação de pena diversa da

corporal.

Por fim, ao cabo, e de saída, entendo inaplicável o disposto no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, à mingua de informações hábeis a respaldar a real situação processual do acionado, como um todo, de forma a permitir identificar a presença do requisito subjetivo, que indispensável à estipulação de regime diverso do imposto, já que se trata de uma forma, ou de outra, de verdadeira progressão, afeta ao Juízo da execução (art. 66, inciso III, da LEP).

Neste sentido: Apelação nº 0090669-32.2012, rel. Desembargador Roberto Solimene; Apelação nº 0008232-62.2010, rel. Desembargador Fernando Torres Garcia.

Ademais, tendo em conta a pena aplicada, e o tempo de custódia que descontou até então, não faz jus a qualquer benefício.

Acredito que mais, seja desnecessário aduzir, posto que nada mais pertine à análise, como forma de dirimir a controvérsia instalada.

Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE o pedido e assim o faço para CONDENAR o réu ALECSOM DA SILVA CRUZ ao cumprimento de pena privativa de liberdade de seis anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de pena pecuniária em valor equivalente a seiscentos dias multa, fixados estes em seu valor unitário mínimo, na forma do art. 43 da Lei nº 11.343/06, por infringência ao disposto nos art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Sensíveis os requisitos que fundamentaram a conversão da prisão em flagrante em preventiva do réu, e ainda mais agora, tendo sido condenado a duras penas, de modo que, acaso posto em liberdade, invariavelmente não se colocará de modo voluntário ao cumprimento de suas reprimendas, mantenho a prisão preventiva do sentenciado. Assim se garante a ordem pública, bem como a aplicação da lei penal.

Transitada esta em julgado, que seja o nome do réu lançado no rol dos culpados, transferindo-se o valor de R\$ 108,00, apreendido a fls. 06/07 (comprovante de depósito judicial a fls. 50) em favor do FUNAD, eis que se trata de evidente produto do comércio espúrio de drogas.

Arcará o condenado, com o pagamento das custas do processo, nos termos do art. 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/03, porém, nos termos e limites do art. 98, § 3º, do Novo Código de Processo Civil.

Sentença dada e publicada em audiência, saindo os presentes cientes e intimados.

P.R.I.C.

São Paulo, 15 de setembro de 2022.

Marcio Lucio Falavigna Sauandag
Juiz de Direito Titular I da 22ª Vara Criminal Central

Assinatura digital, nos termos do art. 1º, § 2º, inciso III, alínea "a", da Lei Federal nº 11.419/06